



Le fonti del diritto

Il sistema delle fonti

Definizione di fonti del diritto

a) fonti di produzione del diritto: fatti o atti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche

Fonti atto (atti normativi): atti normativi emanati da organi ai quali l'ordinamento attribuisce il potere di produrre norme giuridiche. Es: la legge; i regolamenti parlamentari

Fonti fatto: norme non scritte che originano da comportamenti della collettività, che si ripetono in maniera spontanea e costante nel tempo, e che sono considerati idonei a produrre norme giuridiche. Es: usi e consuetudini

Elementi che determinano caratterizzano le fonti fatto:

- L'elemento oggettivo: è un **comportamento consolidato** (cioè tenuto in modo uniforme e costante nel tempo) e **generalizzato** (relativo ad una collettività/ gruppo di persone).
- l'elemento soggettivo: il **convincimento che la condotta ripetuta nel tempo sia tenuta in osservanza di una norma.**



Segue: fonti sulla produzione e fonti di cognizione

b) fonti sulla produzione: norme che disciplinano le modalità di produzione delle regole giuridiche (individuano gli organi titolari del potere di produrre norme giuridiche; i procedimenti di formazione di tali norme; le caratteristiche degli atti normativi). Gli artt. 70 Cost., 76 e 77 Cost. sono fonti sulla produzione, per quanto riguarda la legge e gli atti aventi forza di legge.

c) Le fonti di cognizione: documenti attraverso i quali le norme giuridiche sono portate a conoscenza. Es: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i bollettini ufficiali della Regione e la Gazzetta Ufficiale dell'UE.



La risoluzione delle antinomie delle fonti

Per antinomia si intende un contrasto tra fonti.

La presenza di antinomie nell'ordinamento giuridico costituisce un fenomeno normale, legato alla pluralità di fonti che lo compongono.

Per questa ragione, l'ordinamento prevede una serie di criteri per risolvere in via interpretativa le antinomie tra le fonti del diritto.

Criteri per risolvere le antinomie fra le fonti:

- a) Il criterio gerarchico
- b) Il criterio cronologico
- c) Il criterio di specialità
- d) Il criterio di competenza



Il criterio gerarchico

In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che occupa la **collocazione più elevata nella scala gerarchica** delle fonti (lex superior derogat legi inferiori).

La prevalenza della norma superiore su quella inferiore opera attraverso l'**ANNULLAMENTO**.

L'annullamento è l'effetto tipico che deriva da una **DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ**, la quale determina la perdita di validità dell'atto riconosciuto in contrasto con una fonte di rango superiore (ES.: la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge per contrasto con la Costituzione).

L'ANNULLAMENTO deve sempre essere dichiarato da un giudice con una sentenza di natura costitutiva.

Gli effetti del criterio gerarchico: l'annullamento

L'ANNULLAMENTO ha **efficacia erga omnes** e opera anche per il passato (**ex tunc**). La norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita

➤ **unica eccezione** alla efficacia retroattiva dell'annullamento: i **rapporti esauriti**

L'ATTO E' ANNULATO PERCHE' INVALIDO, OSSIA AFFETTO DA UN VIZIO DI LEGITTIMITA'

I vizi di legittimità possono essere di due tipi:

- **FORMALI**: riguardano la competenza dell'organo che ha emanato l'atto normativo e la procedura per l'adozione dell'atto.
- **SOSTANZIALI**: riguardano il contenuto dell'atto normativo, che risulta in conflitto con il contenuto di una disposizione di rango superiore.



La gerarchia delle fonti del diritto italiano

1) Le fonti di rango costituzionale: la Costituzione; leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.); gli statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.)

2) Le fonti primarie. Sono fondate sulla Costituzione e da questa disciplinate: la legge ordinaria dello Stato (artt. 70 ss.); i decreti legislativi e i decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); i regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.); gli statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); le leggi regionali (artt. 117 Cost.)

NB: Sono un «**sistema chiuso**»: non esistono fonti primarie al di là di quelle previste espressamente dalla Costituzione

3) Le fonti secondarie. Devono essere deliberate sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) e sono le norme subordinate alla legge: regolamenti dell'Esecutivo

4) Usi e consuetudini: devono essere richiamati dalla legge (possono quindi esistere solo consuetudini *secundum legem* e *praeter legem*, non *contra legem*)

Il criterio cronologico

- Riguarda norme di pari grado.
- La norma più recente prevale su quella precedente (*lex posterior derogat priori*).
- Tale criterio opera solo tra fonti di **pari grado** e **omogenee** (tra leggi; tra leggi e atti aventi forza di legge; tra regolamenti dell'esecutivo)
- Secondo il criterio cronologico, la prevalenza della nuova norma sulla vecchia opera attraverso l'**ABROGAZIONE**: delimitazione dell'efficacia della legge precedente.
- L'ABROGAZIONE, per il principio di non retroattività degli atti normativi (**art. 11 Preleggi**), opera solo per il futuro (**ex nunc**, ossia da ora) e quindi delimita l'efficacia nel tempo della norma precedente (che continuerà ad essere applicata ai rapporti sorti sotto la sua vigenza, ma non a quelli sorti sotto la vigenza della norma più recente).



Gli effetti dell'abrogazione

T1

|

Legge X

T2

|

Legge Y





I tipi di abrogazione: la differenza fra disposizione e norma

- **DISPOSIZIONE:** la formulazione linguistica di un atto normativo, il testo dato dalla connessione delle proposizioni linguistiche utilizzate dal legislatore
- **NORMA:** significato che si ricava dalla disposizione attraverso l'attività interpretativa di una disposizione

tipologie di abrogazione

Secondo l'**art. 15** delle **disposizioni preliminari al C.c.**, l'abrogazione può essere:

- a) espressa:** avviene sulla base di una dichiarazione espressa del legislatore. Essendo disposta dal legislatore, **ha valore erga omnes** (anche l'abrogazione che avviene con **referendum abrogativo** è sempre una abrogazione espressa)
- b) Per incompatibilità con la nuova disciplina (tacita):** determinata dalla incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, senza che il legislatore individui le disposizioni della precedente disciplina che sono abrogate. E' l'interprete che determina quali norme preesistenti risultano abrogate (**ha efficacia inter partes**: nel giudizio deciso dal giudice)
- c) Per nuova disciplina (implicita):** quando la nuova normativa regola l'intera materia già regolata dalla disciplina precedente, senza che il legislatore individui le norme della precedente disciplina che sono abrogate. E' l'interprete che determina quali norme preesistenti risultano abrogate (**ha efficacia inter partes**: nel giudizio deciso dal giudice)

Il criterio di specialità

In caso di contrasto tra due norme, si deve preferire la norma speciale rispetto a quella generale, anche qualora questa sia successiva (*lex specialis derogat legi generali*), anche quando la norma generale sia successiva.

NB: La legge speciale, quindi, resiste all'abrogazione della legge generale.

Il contrasto tra norme di tipo diverso, una di carattere generale e una di carattere particolare, è risolto attraverso la **DEROGA**. La norma generale è derogata dalla norma particolare, la quale rappresenta un'eccezione alla regola.

La norma derogata **non perde la propria efficacia e validità**, ma viene semplicemente limitato il suo ambito di applicazione. L'interprete **opera una scelta** e applicherà la norma speciale. La norma generale, valida ed efficace, semplicemente non sarà applicata.

La **DEROGA** ha efficacia *inter partes* (solo rispetto al caso preso in esame dal giudice)

Il criterio della competenza

Il criterio della competenza è connesso alla RIGIDITA' DELLA COSTITUZIONE e viene in rilievo perché la disciplina di determinati settori è **riservata dalla Costituzione** (o dalle leggi costituzionali) in via esclusiva a determinati atti normativi diversi dalla legge del Parlamento

Riguarda **fonti separate dalla legge del Parlamento**, in quanto ad esse la Costituzione attribuisce una specifica competenza normativa.

ESEMPI: l'organizzazione delle Camere è affidata dall'art. 64 Cost. ai regolamenti parlamentari ex **art. 64**, co. 1, Cost.; **l'art. 117 Cost.** attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni la disciplina di alcune materie; sulla base **dell'art. 11 Cost.** lo Stato ha attribuito, nelle materie indicate nel TUE, poteri normativi alle istituzioni UE.

Sulla base di tale criterio, in caso di contrasto tra due norme occorre preferire quella che, sulla base della Costituzione, ha una competenza riservata a disciplinare una determinata MATERIA (la fonte competente)

Il criterio della competenza riguarda fonti separate dalla legge

- **SEPARAZIONE PER AMBITI MATERIALI:** alla fonte separata è attribuita la disciplina di una determinata materia che quindi è sottratta alla legge (**art. 64 Cost.**)
- **SEPARAZIONE PER MODI DI DISCIPLINA:** sulla stessa materia intervengono sia la legge, sia la fonte separata ma con una diversa modalità di disciplina. ESEMPIO: **l'art. 117, III c., Cost.** prevede la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in alcune materie. In queste materie intervengono sia la legge statale sia la legge regionale, tuttavia la legge statale ha il compito di determinare i principi fondamentali della materia regolata, mentre la legge regionale ha il compito di delineare la disciplina di dettaglio, adeguando i principi alla realtà del territorio regionale.

Come opera il criterio di competenza

Il criterio della competenza è **privo di autonomia concettuale**, in quanto il contrasto tra la legge e la fonte a competenza riservata può essere risolto ricorrendo al criterio gerarchico oppure al criterio di specialità:

- **Criterio gerarchico:** la norma di legge viene annullata in quanto in contrasto con la norma costituzionale che attribuisce la disciplina di una determinata materia ad una fonte a competenza riservata (es: art. 64 Cost. per il regolamento parlamentare)
- **Criterio di specialità:** l'interprete può considerare la legge valida per l'ordinamento generale, ma non la applica alla materia in cui la Costituzione prevede la disciplina di una fonte a competenza riservata (ad es: il regolamento parlamentare). Il giudice applica quindi la norma speciale in luogo della norma generale.